

1501259-70.2021.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gisela Ruffo

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/02/2022

... qualquer suspeita da prática do tráfico de drogas a ensejar a busca pessoal, revestindo-a, portanto, de ilegalidade. Nesse sentido, observe-se o recente entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça: RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA ILÍCITA. REVISTA PESSOAL E VEICULAR REALIZADA POR GUARDA MUNICIPAL. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. NÃO ...

,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

4ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Alemães, Piracicaba - 13417-901 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1501259-70.2021.8.26.0599 - Controle nº 2021/000926

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2220701/2021 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 19623173 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO,

2218/21/922 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 2220701 - 02º D.P. PIRACICABA,

2218/21/922 - 02º D.P. PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO FELIPE DOS SANTOS

Aos 22 de fevereiro de 2022, às 13:30h, através de videoconferência na aplicação Microsoft Teams, nos moldes do Comunicado CGJ nº 284/2020 em razão da pandemia do coronavírus, realizou-se a presente audiência, sob a presidência da MMª. Juíza de Direito, Dra. Gisela Ruffo, comigo Escrevente ao final nomeado.

Representante do Ministério Público: Dra. FERNANDA GUIMARÃES ROLIM BERRETA - PRESENTE (via videoconferência)

.

Réu: DIEGO FELIPE DOS SANTOS - PRESENTE (via videoconferência)

Defensor Público: Dr. RAFAEL BRESCIANI MARRACINI - PRESENTE (via videoconferência)

Testemunha comum: GC SÉRGIO ALEXANDRE SOARES FRANZIN - PRESENTE (via videoconferência)

Testemunha comum: GC JOSÉ ANTÔNIO DE SOUZA OLIVEIRA - PRESENTE (via videoconferência)

Iniciados os trabalhos, foi colhido o depoimento da testemunha GC SÉRGIO ALEXANDRE SOARES FRANZIN.

Dada a palavra à Dra. Promotora, por ela foi dito que desistia da oitiva da testemunha JOSÉ ANTÔNIO DE SOUZA OLIVEIRA, o que foi homologado pela MMª. Juíza. Dada a palavra à Defesa, por ela foi dito que desistia da oitiva da testemunha JOSÉ ANTÔNIO DE SOUZA OLIVEIRA, o que foi homologado pela MMª. Juíza.

Após, o réu DIEGO FELIPE DOS SANTOS foi devidamente interrogado.

O(s) depoimento(s) e o(s) interrogatório(s) foi(foram) captado(s) e gravado(s) em vídeo e a(s) mídias(s) está(ão) disponível(veis) no presente termo, no Sistema SAJ. A seguir, pela MMª. Juíza foi declarada encerrada a instrução, determinando que as partes se manifestassem em alegações finais.

Pela Dra. Promotora de Justiça foi dito o seguinte: "DIEGO FELIPE DOS SANTOS, já qualificado nos autos em epígrafe, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 pelas condutas delituosas descritas na exordial acusatória de fls. 83/85. O processo teve andamento regular. Devidamente notificado (fls. 102), o réu apresentou sua defesa preliminar (fls. 106/107), sendo a denúncia recebida (fls. 108/110). Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e o réu, por fim, interrogado. Em síntese, o necessário. Passa-se à manifestação. A prova produzida impõe a procedência da ação penal. A materialidade delitiva do tráfico de entorpecentes está consubstanciada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 09/10, fotografia de fls. 12 e pelo laudo de exame químico toxicológico definitivo de fls. 90/92. A autoria é incontroversa. O guarda municipal Sergio Alexandre Soares Franzin, confirmando suas declarações prestadas na fase investigativa, narrou que estavam em patrulhamento regular pelo local dos fatos, já bastante conhecido como ponto de venda de drogas, quando em determinado momento avistaram o réu andando pela via, com uma sacola nas mãos, o qual, ao visualizar a viatura, mudou a direção de maneira suspeita e começou a disfarçar. Ante a suspeita conduta, realizaram sua abordagem. Disse que, em revista pessoal, encontrou o valor de dois reais na posse do réu e, dentro da sacola que ele segurava, localizaram uma porção de maconha e dezenove porções de cocaína. Afirmou que, de maneira informal, o acusado disse que a maconha era para consumo pessoal e, quanto às porções de cocaína, disse que o gerente do tráfico na região, não identificado, o incumbiu de abastecer os demais traficantes do bairro, os quais também não identificou. No mesmo sentido foram as palavras do guarda municipal José Antônio de Souza Oliveira, ouvido apenas na fase policial. Por fim, interrogado, o réu negou os fatos a si atribuídos, alegando que foi até o local e, na frente do mercado ali existente, comprou de um adolescente que ali estava as drogas consigo apreendidas para seu próprio uso. Disse ser usuário de cocaína e negou que tivesse uma porção de maconha para seu uso. Assim, em que pese a negativa do réu quanto aos fatos, sua versão não deve prevalecer, vez que dissonante e isolada das demais provas coligidas nos autos, não encontrando nelas qualquer respaldo. De fato, é certo que os guardas municipais foram uníssonos ao afirmar que o acusado estava em local conhecido como de venda de drogas, em poder de 19 porções de cocaína, além de uma de maconha, tendo ele tentado disfarçar e deixar o local ao visualizar a viatura. Ainda, o guarda ouvido confirmou que, ao ser questionado, o acusado confessou informalmente que a mando do gerente do tráfico do bairro iria abastecer pontos de venda de drogas, sendo que a porção de maconha era para seu próprio uso. Vale ressaltar, por oportuno, que os depoimentos prestados pelos guardas são plenamente válidos como meio de prova, se produzidos sob o crivo do contraditório e se estiverem coerentes com as demais provas produzidas, como ocorre no caso em tela. Nesse sentido já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça, nos termos do voto do Ministro Arnaldo Esteves Lima, no julgamento do HC nº 123293/MS, publicado no dia 16/11/2009, do qual se extrai o seguinte trecho: O depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo funcionar como meio probatório válido para fundamentar a condenação, mormente quando colhido em juízo, com a observância do contraditório, e

em harmonia com os demais elementos de prova. Ainda nesse sentido: PROVA - TESTEMUNHA - Depoimento de agentes policiais - Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas - Análise que se faz em cada caso concreto - Inexistência de dúvida que justifica o decreto condenatório - O testemunho de policiais, que no cumprimento de sua missão atuam na repressão penal, é tão válido como de qualquer outro testemunho - Merecem credibilidade e se de acordo ou conformidade com as demais provas, justificam um decreto condenatório - Entendimento - Precedentes - Recurso parcialmente provido. (Apelação n. 990.08.180251-1 - Birigui - 16ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Newton de Oliveira Neves - 04/05/2010 - 8640 - Unânime). (Grifei). Destarte, tem-se que o crime de tráfico descrito na denúncia restou bem comprovado, sendo a condenação de rigor. Quanto à aplicação da reprimenda, tem-se que o réu é tecnicamente primário. Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes. Na terceira fase, presentes os requisitos legais, cabível o redutor previsto no art. 33, § 4º da Lei de Drogas. Requeiro, por fim, seja decretado o perdimento do valor apreendido com o acusado, consistente em R\$ 2,00 (dois reais), com fulcro nos artigos 61 e 63, ambos da Lei nº 11.343/2006. Diante do exposto, o Ministério Público requer e aguarda a procedência da ação, com a condenação do acusado nos termos da denúncia".

Pela Defesa foi dito o seguinte: "MM. Juíza, o acusado foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, na forma como descrito na exordial. Encerrada a instrução probatória nesta data, a Defensoria Pública entende, EM SEDE PRELIMINAR, que as provas obtidas nos autos, em especial as substâncias entorpecentes encontradas pelos Guardas Municipais são ilícitas, eis que a abordagem e a prisão do acusado decorreu de autoridades incompetentes. Com efeito, de acordo com a Constituição Federal de 1988, no seu artigo 144, § 8º, os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei, sendo o referido dispositivo reproduzido de forma idêntica na Constituição do Estado de São Paulo. Portanto, de acordo com as referidas disposições, vislumbra-se que a atual ordem jurídica contempla quais são as específicas atribuições da Guarda Municipal, órgão ao qual incumbe a defesa e proteção dos bens, serviços e instalações em âmbito municipal. Ou seja, as Guardas Municipais não têm status de polícia ostensiva, função esta que cabe a Polícia Militar do Estado de São Paulo. No caso em tela, verifica-se que houve flagrante invasão de competência material, pois a Guarda Municipal atuou como se fosse polícia ostensiva. Nesse aspecto, cumpre mencionar que os Guardas, de forma ilegal, abordaram o acusado sem que qualquer situação de flagrante delito estivesse visível, ainda que fossem autoridades incompetentes para tanto. Essa função, todavia, não incumbe aos Guardas Municipais, mas à Polícia Militar. Na realidade, os Guardas Municipais, diante do fato, deveriam ter acionado o órgão competente para atender à ocorrência. Na atual ordem jurídica, existe a polícia ostensiva, representada pela Militar, e a polícia judiciária, representada pela Civil. Assim, os Guardas jamais poderiam ter atuado como se possuísem aptidão para tanto. Há, no caso em comento, evidente invasão de competência administrativa, de índole constitucional, o que enseja a ilegalidade do ato (prisão em flagrante) e de todas as provas carreadas aos autos, visto que elas são provenientes, todas, de atos dos aludidos Guardas Municipais que atuaram como polícia ostensiva, em flagrante desrespeito às suas atribuições constitucionais. Neste sentido, já se manifestou o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo: "Ação Penal - Desarmamento - Guarda Municipal - Ação de polícia ostensiva - Ilegalidade - Apelo provido para absolver o acusado." (TJSP, ACri nº 990.09.226504-0 - 2ª câmara de direito criminal - origem: Piracicaba/SP, julg. 1º/02/10); "Apelação Criminal Tráfico de entorpecentes - Prisão dos réus efetuada por Guardas Municipais - Afirmação dos servidores da realização de campanha para confirmar o crime - ilegalidade da ação reconhecida - Admissão, no caso presente, da existência de prova que contamina a ação penal Apelo provido para absolver os réus." (TJSP, ACri nº 0032340-54.2011.8.26.0602 - 2ª Câmara de Direito Criminal - origem: Sorocaba/SP, julg. 12/11/2012). Inclusive, nas palavras do Ilustre Desembargador relator da Apelação Criminal nº 0032340-54.2011.8.26.0602, cuja ementa se encontra acima transcrita e

que teve origem na Comarca de Sorocaba/SP, onde também é usual que a Guarda Municipal exerça as tarefas da polícia ostensiva, defendeu, com grande propriedade, o Dr. Almeida Sampaio: “Fica delineado, de maneira bastante evidente, portanto, que, dentro da divisão das atribuições das Polícias, somente à Militar é outorgado constitucionalmente o poder de exercer o policiamento ostensivo, cabendo tão-somente à Guarda Municipal a proteção de seus bens, serviços e instalações”. E ainda: “Em razão da Constituição de 1988, todos os entendimentos jurisprudenciais e a legislação que não se coadunem com a norma perderam sua validade. Enquanto não ocorrer alteração dos dispositivos acima transcritos, fica rejeitada a validade da ação de Guarda Municipal que, em ação de policiamento ostensivo, efetua diligências para prender eventual traficante.”. Por fim, é cediço que qualquer pessoa do povo pode efetuar a prisão em flagrante – embora essa situação não tenha restado demonstrada nos autos, eis que o acusado não foi visto praticando atos que indicassem o comércio de entorpecentes – e, por isso, em tese, a Guarda Municipal também teria esse poder. Contudo, o que não é permitido é que uma Instituição que tem por função a proteção do patrimônio público se utilize de um poder que não possui e atenda ocorrências, realize investigações e efetue abordagens, a fim de efetuar uma prisão em flagrante. Entretanto, caso não sejam acolhidos os argumentos formulados, ainda em sede PRELIMINAR, verifica-se que as provas também são ilícitas porque foram constituídas a partir de uma busca pessoal irregular. Com efeito, em relação à busca pessoal, é de se observar que ela não observou os requisitos previstos no artigo 240 do Código de Processo Penal. Isso porque os Guardas Municipais declararam que fizeram a abordagem do réu porque ele “mudou a direção em que caminhava e disfarçou ao ver a viatura”, sem fossem visualizadas condutas prévias que indicassem o seu envolvimento no comércio de entorpecentes ou que existissem sequer denúncias a respeito do acusado. Ora, evidente, portanto, que não havia qualquer suspeita da prática do tráfico de drogas a ensejar a busca pessoal, revestindo-a, portanto, de ilegalidade. Nesse sentido, observe-se o recente entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça: RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA ILÍCITA. REVISTA PESSOAL E VEICULAR REALIZADA POR GUARDA MUNICIPAL. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA NÃO VERIFICADA. ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 1. Considera-se ilícita a busca pessoal, domiciliar pessoal e veicular executadas por guardas municipais sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos do art. § 2º do art. 240 do CPP, bem como a prova derivada da busca pessoal. 2. Tendo a busca pessoal ocorrido apenas com base em parâmetros subjetivos dos agentes de segurança, sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva, deve ser reconhecida a ilegalidade por ilicitude da prova, determinando-se o trancamento da ação penal. 3. Recurso em habeas corpus provido para declarar ilegal a apreensão e, consequentemente, determinar o trancamento da ação penal. (RHC 142.588/PR, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021). Todavia, caso sejam rejeitadas todas as preliminares suscitadas pela Defensoria Pública, QUANTO AO MÉRITO, verifica-se que deverá ocorrer a ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO POR FALTA DE PROVAS. Excelência, como se sabe, a Constituição Federal garante a presunção de inocência, de tal sorte que se faz necessário um conjunto probatório robusto e harmônico para que se autorize a prolação de um decreto condenatório. Nesta data, a testemunha Sérgio, GCM, declarou que estavam em patrulhamento pelo local dos fatos, conhecido pela movimentação do tráfico de drogas. Visualizaram o réu, sendo que, ao ver a presença da equipe, ele começou a “disfarçar” e olhar para cima. Ele segurava um objeto nas mãos. Por conta disso, efetuararam a abordagem do acusado. Em poder dele, encontraram 19 porções de cocaína e uma porção de maconha, além da quantia de R\$ 2,00. O réu disse que a maconha era para seu consumo pessoal e a cocaína seria para comercialização, sendo que ele levaria o entorpecente para outras pessoas efetuarem a venda. O acusado estava sozinho. Não conhecia o réu antes dos fatos. O réu, em interrogatório, declarou que foi preso próximo a um supermercado. Comprou as drogas de um outro indivíduo que estava no local e estava voltando pra casa quando encontrou os GCM. Por isso disfarçou quando viu a viatura. Já passou por diversas clínicas de

recuperação, é usuário de entorpecentes. Usa cocaína. Não sabe a origem da maconha. Os pinos de cocaína estavam no seu bolso. Pagou R\$ 190,00 pelas porções de cocaína. Trabalhava na época em uma hamburgueria próxima à Rua do Porto. Recebia cerca de R\$ 1.900,00 por mês. Ia consumir o entorpecente em cerca de 03 dias. Geralmente usava mais drogas durante o final de semana. Não conhecia os Guardas que efetuaram a sua prisão. Excelência, o acusado, como visto, nega a prática do tráfico de drogas. Sua negativa deve ser considerada um elemento probatório, afastando-se qualquer juízo preconceituoso que se tenha contra ela, sobretudo porque não refutada pelas demais provas dos autos. Isso porque as provas reunidas pela acusação se resumem às palavras dos Guardas responsáveis pela prisão do réu. Com efeito, mister destacar, neste ponto, que a Defensoria Pública não pretende desqualificar a nobreza ou a honestidade de uma instituição responsável pela segurança pública do Estado ou negar a força probatória dos depoimentos dos agentes, embora seja inegável que eles, na grande maioria das vezes, ratifiquem, em juízo, a versão apresentada quando da realização da prisão, inclusive como forma de convalidar o ato e seus respectivos efeitos. Sustenta a Defensoria Pública, na realidade, que os depoimentos dos agentes, sem amparo de outras provas que estejam ao alcance dos órgãos responsáveis pela persecução penal, não podem servir de fundamento para a prolação de uma sentença condenatória, sob pena de se atribuir à referida prova caráter quase absoluto no processo penal, fragilizando as garantias do devido processo legal e da ampla defesa, bem como inviabilizando a busca da verdade processual. Aliás, em se tratando de delitos de drogas, o E. Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de não admitir as palavras dos Policiais como fundamento para uma condenação, verbis: "Assim, o que se verifica, é

que a condenação foi amparada exclusivamente nas declarações policiais, o que se revela insuficiente. É que seus testemunhos tem qualificação e natureza diversas de qualquer outro. São relatos de agentes policiais, ou seja, a longa manus do próprio aparelho repressor, de modo que as teorizações jurídicas processuais de âmbito criminal não podem ignorar a realidade fática. O policial é o agente operacional da repressão e não depõe com a imparcialidade das demais testemunhas, ainda que de modo inconsciente. Sua visão sobre os fatos, o seu entendimento sobre as circunstâncias que apurou, são do próprio sistema repressor, dos quais o garantismo constitucional do devido processo legal objetiva proteger." (TJSP - 7ª Câmara Criminal - Ap. 0020153-57.2006.8.26.0224 -- Rel. Francisco Menin - j. 03/02/11 - grifado). Inclusive, no caso em pauta, verifica-se que, a despeito das declarações dos Policiais, nenhum ato efetivo de comércio foi avistado antes da abordagem, além de não terem sido apresentados outros indivíduos como eventuais compradores das substâncias entorpecentes e/ou testemunhas presenciais dos fatos. Ademais, a mera afirmação de que o local dos fatos seria um ponto de tráfico não acarreta a presunção de que o acusado estaria envolvido com o crime, eis que, nesses locais, circulam tanto indivíduos que se dedicam ao comércio de drogas quanto usuários dessas substâncias. E a suposta confissão informal do acusado, além de constituir uma circunstância aberrante, que destoa do ordenamento jurídico, não foi confirmada em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Por fim, também é importante mencionar que, recentemente, o E. Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu, em v. acórdão proferido pela 11ª Câmara de Direito Criminal, que somente a quantidade e variedade de drogas apreendidas com uma pessoa não são elementos suficientes para a caracterização do tráfico, sendo necessários outros fundamentos concretos que atestem o envolvimento do agente no comércio de entorpecentes (Proc. 000843-44.2017.8.26.0559). Dessa forma, ante a manifesta insuficiência probatória, a absolvição é medida de rigor, nos termos do artigo 386, VII, do CPP. Entretanto, na hipótese deste E. Juízo afastar o pleito absolutório, requer-se, ao menos, diante das declarações do acusado em seu interrogatório, a DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES PARA O TIPO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. Isso porque, com a devida vênia, há de se reconhecer que não há nos autos indícios de que o acusado fosse comercializar as drogas apreendidas, sendo que, reitera-se, não foi verificado qualquer ato efetivo de mercancia dos entorpecentes. Assim, no máximo, o réu poderia ser responsabilizado por portar drogas para fins de consumo pessoal, pois não foi demonstrado cabalmente o intuito

lucrativo, não bastando a simples apreensão do entorpecente em poder do acusado para se justificar uma condenação por tráfico. Vale observar, ainda, que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas em poder do réu nada diz quanto à sua destinação, eis que a quantidade necessária para a satisfação de um usuário é completamente variável. Para a configuração do crime de tráfico, não basta a simples apreensão da droga, sendo imprescindível a aferição de prova cabal da finalidade de mercancia dos entorpecentes por parte do réu, o que não foi o caso. Todavia, caso mantida a condenação pelo tráfico de drogas, requer-se, então, a APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. É que, na hipótese vertente, encontram-se presentes todos os requisitos para a sua incidência, vez que o acusado, à época dos fatos, era tecnicamente primário. Ademais, não há prova de que ele participe de organização criminosa ou que se dedique à prática de atividades ilícitas, o que não pode ser presumido apenas em função da quantidade de entorpecentes que fora apreendida, que, aliás, nem mesmo se mostra elevada, na hipótese. Neste ponto, cumpre ressaltar que, para que ocorra “dedicação às atividades criminosas”, faz-se necessário que o agente pratique não um ou dois crimes, mas diversos atos ilícitos periodicamente, que faça de sua atividade cotidiana o cometimento de crimes, o que, no caso, não se deu. Além disto, o Decreto 5.015/04, que promulga a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, define, em seu artigo 2º, o conceito de organização criminosa: “Artigo 2º – Terminologia. Para efeitos da presente Convenção, entende-se por: a) “Grupo criminoso organizado” - grupo estruturado de três ou mais pessoas, existente há algum tempo e atuando concertadamente com o propósito de cometer uma ou mais infrações graves ou enunciadas na presente Convenção, com a intenção de obter, direta ou indiretamente, um benefício econômico ou outro benefício material; (...). Do cotejo do texto legal acima citado, é evidente que não se configurou uma organização criminosa. Assim, quanto a “integrar organização criminosa”, é possível afirmar que a intenção do legislador foi vedar a aplicação da causa de diminuição de pena em seu grau máximo àquele que é membro de organização criminosa, ou seja, possui vínculo de forma ativa e permanente com a mesma, além de grande envolvimento com seus mecanismos e pessoas, o que, à evidência, não ocorre na hipótese em testilha. Finalmente, cabe observar que, consoante entendimento jurisprudencial pacífico, a quantidade de entorpecentes apreendida não basta, por si só, para afastar a incidência do redutor, se presentes seus requisitos legais. Na mesma linha, é o entendimento doutrinário, como bem aponta Luiz Flávio Gomes, verbis: “No delito de tráfico (art. 33, caput) e nas formas equiparadas (§ 1º), as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário (não reincidente), de bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa (traficante, agindo de modo individual e ocasional). Os requisitos são subjetivos e cumulativos, isto é, faltando um deles, inviável a benesse legal. A simples leitura do parágrafo pode induzir o intérprete a imaginar que o benefício está na órbita discricionária do juiz. Contudo, parece-nos que, preenchidos os requisitos, o magistrado não só pode como deve reduzir a pena, ficando sua discricionariedade (motivada) limitada à fração minorante (esta orientada pela quantidade e/ou espécie de droga apreendida)” (Lei de Drogas Comentada, 5ª edição, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2013, p. 178 – grifado). Assim, plenamente identificados os requisitos legais, deve incidir a hipótese de redução estampada no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Por fim, caso não sejam acolhidas as teses anteriores, a defesa requer, no tocante à dosimetria da pena: (i) a fixação da pena-base no patamar mínimo previsto na lei, ressaltando-se a pouca quantidade e diversidade de entorpecentes apreendida, e que as demais circunstâncias previstas no art. 59 do CP são favoráveis ao réu, tecnicamente primário; (ii) a incidência, na segunda fase da dosimetria, da atenuante da confissão espontânea (ainda que informal); (iii) a incidência, na terceira fase da dosimetria, do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, como sustentado; (iv) seja fixado o regime menos gravoso do que o fechado para início do cumprimento da pena, com as substituições de pena que se mostrarem cabíveis, considerando o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, que impunha, obrigatoriamente, o início do

cumprimento da pena no regime fechado, em relação aos crimes hediondos e os a ele equiparados (STF – Pleno – HC nº 111.840/ES – rel. Min. Dias Toffoli), em atenção, ainda às súmulas nº 718 e 719, do E. STF e das súmulas nºs 269 e 440 do E. STJ; (v) seja concedida ao acusado a possibilidade de aguardar o julgamento de eventual recurso em liberdade, haja vista que ele foi solto durante o processamento do feito e inexistente fato concreto que autorize, neste momento, a decretação de sua prisão preventiva".

A seguir, pela MMª. Juíza foi proferida a Sentença a seguir:
"Vistos.

DIEGO FELIPE DO SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 14 de agosto de 2021, por volta das 13h51min, na Rua Monsenhor Bastos, nº 1209, Bairro Água Branca, via pública, nesta cidade e comarca de Piracicaba, trazia consigo, para inequívocos fins de comercialização a terceiros, 19 (dezenove) "ependorfs" de cocaína em pó, pesando cerca de 5,7g (cinco gramas e sete decigramas), e 01 (uma) porção de maconha, com peso líquido de 1,7g (um grama e sete decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Narra a denúncia que guardas municipais estavam em regular patrulhamento pelo local dos fatos, já conhecido como ponto de venda de drogas, quando visualizaram o acusado caminhando pela via pública com uma sacola em uma das mãos, o qual, ao avistar a viatura, mudou de direção de maneira suspeita. Em razão disso, os guardas procederam à abordagem e apreenderam na posse de DIEGO os entorpecentes retro descritos, que estavam no interior da sacola que ele trazia consigo, e a quantia de R\$ 2,00 em espécie. Indagado, DIEGO afirmou que, a mando do gerente do tráfico daquela região, iria abastecer os demais traficantes do bairro com os "pinos" de cocaína, ao passo que a porção de maconha era para seu consumo pessoal.

O réu foi notificado nos termos do art. 55 da Lei 11.343/06 (fls. 102) e apresentou defesa preliminar (fls. 106/107), seguindo-se a decisão que recebeu a denúncia (fls. 108/110).

Durante a instrução, foi ouvida uma testemunha arrolada na denúncia e interrogado o réu.

As partes apresentaram alegações finais.

É o relatório.

Fundamento e decido.

1. O E. Supremo Tribunal Federal, a fim de coibir excessos e arbitrariedade, assentou entendimento segundo o qual o ingresso em residência, sem autorização do morador e sem ordem judicial, para ser lícito, demanda quadro de fundada suspeita de situação de flagrante delito. Logo, os policiais somente podem adentrar em residência se tiverem dados concretos indicativos da ocorrência de um crime, impondo-se controle jurisdicional posterior da diligência para se definir se a ação policial era justificada ou não.

Confira-se, sobre o tema, o julgado em que assentado o entendimento do Pretório Excelso: "Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral.

2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protraí no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori.

Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa

Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (STF, RE nº 603.616/RO, rel. Min. Gilmar Mendes).

Esse mesmo entendimento pode ser aplicado à busca pessoal, face ao que dispõe o art. 240, § 2º, do CPP.

No caso em tela, os guardas civis esclareceram que faziam patrulhamento em local conhecido como ponto de tráfico e avistaram o réu no local, em atitude suspeita, eis que segurava uma sacola e, ao notar a presença da viatura, tentou disfarçar, o que ele mesmo admitiu.

A abordagem do acusado não constituiu, portanto, ação arbitrária. Havia justa causa para a ação, sendo lícitas as provas daí decorrentes.

E tampouco houve ilegalidade na conduta dos guardas municipais, já que, conforme dispõe a lei, qualquer do povo pode efetuar prisão em flagrante delito (art. 301 do Código de Processo Penal). Aliás, seria absurdo imaginar-se que os guardas municipais, informados da prática criminosa, não pudessem tomar providências para fazer cessar a infração, ficando, passivamente, no aguardo da chegada de policiais civis ou militares (cf. Apelação nº 0019493-07.2010.8.26.0068, Rel. Des. CESAR MECCHI MORALES, j. 16.12.14).

2. A prova dos autos é suficiente e segura ao apontar a responsabilidade penal do réu.

A materialidade do crime está comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 09/10, pela fotografia de fls. 12 e pelo laudo de exame químico-toxicológico de fls. 90/92, que trouxe resultado positivo para cocaína e maconha.

A autoria também é certa.

Por ocasião do auto de prisão em flagrante, o réu se valeu do direito de permanecer em silêncio (fls. 05).

Em juízo, negou a prática do crime. Alegou que foi ao local dos fatos e comprou 19 porções de cocaína de um moleque, por R\$ 190,00. Disse que, quando subia a rua, viu a viatura e realmente tentou disfarçar, em razão da droga que tinha em seu poder, mas foi abordado. Asseverou que até falou para os guardas que informaria de quem era a droga, se pudesse ser liberado. Afirmou que é usuário de cocaína e, em seu poder, só havia 19 porções dessa droga, alegando que a maconha não estava com ele. Sustentou que trabalhava numa hamburgueria, recebia R\$ 1.900,00 por mês e usava drogas mais aos finais de semana.

A negativa do réu, porém, foi infirmada pela prova produzida.

O guarda municipal Sérgio Alexandre relatou que estavam realizando patrulhamento em área conhecida pela prática de tráfico de drogas quando visualizaram a presença do réu. Atestou que, ao ver a viatura, ele disfarçou. Disse que ele segurava algo nas mãos e decidiram fazer a abordagem. Atestou que, com ele havia dezenove porções de cocaína e uma de maconha, além de R\$ 19,00. Indagado, o réu falou que a maconha era para uso dele e a cocaína, para comercialização, eis que tinha recebido ordem de uma terceira pessoa para ele levar o entorpecente para outras pessoas venderem.

No mesmo sentido o depoimento do guarda municipal José Antônio (fls. 04).

É de se asseverar que o simples fato de as testemunhas de acusação serem guardas municipais não é o bastante para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que

estes sejam recebidos com reservas. Não estando impedidos, seus depoimentos serão considerados como o de qualquer testemunha, já que nenhuma razão tinham para falsear a verdade, a não serem cumpridores de seus deveres funcionais.

E "como toda testemunha o guarda municipal assume o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da lei, na hipótese de falso testemunho. O depoimento vale não pela condição do depoente, mas pelo seu conteúdo de verdade. Estando em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-lo, apenas por se tratar de policial" (RJTJESP 125/263). Nesse mesmo sentido: RT 591/313, 612/316 e 654/278.

A prova acusatória consistente em depoimentos de guardas municipais é tão válida quanto outra qualquer, desde que tais testemunhos sejam insuspeitos, sérios e coerentes.

Acrescento que a presunção de imparcialidade, retidão e lisura deve ser em favor da autoridade pública, que age no estrito cumprimento do dever legal (cf. RT 738/665). Enfim, o fato de os guardas municipais terem apreendido as porções de maconha e cocaína em poder do réu, o que não foi infirmado por nenhum elemento de prova, conduz à certeza quanto à autoria.

Prosseguindo, a quantidade e diversidade de entorpecente apreendidos e a forma como estavam acondicionados, aliados ao local os fatos, conhecido como ponto de tráfico, deixam evidente que a droga se destinava ao comércio ilícito.

Sobre a viabilidade desses elementos demonstrarem a destinação comercial dos entorpecentes, cito os seguintes precedentes:

"Apelação. TRÁFICO DE DROGAS. Conjunto probatório firme e coeso para manter a responsabilização do réu, notadamente pelos relatos dos policiais e a existência de denúncias anônimas apontando o réu como sendo traficante de drogas. Quantidade e forma de acondicionamento que demonstram a destinação das drogas para a mercancia. Penas. Redução. Possibilidade - Regime prisional incensurável PARCIAL PROVIMENTO AO APELO." (TJ-SP: Apelação Criminal nº 0004053-31.2010.8.26.0242, 10ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Rachid Vaz de Almeida, j. 16/02/2012, v.u.).

"APELAÇÃO CRIMINAL - TRAFICO DE ENTORPECENTES - Inconformismo defensivo. - Materialidade e autoria comprovadas. Relatos dos policiais que encontraram drogas em posse do réu - Quantidade e forma de acondicionamento dos entorpecentes que não deixam dúvidas da narcotraficância - Condenação mantida - Penas bem dosadas que não comportam reparo. Recurso desprovido." (TJ-SP: Apelação Criminal nº 0038185-16.2007.8.26.0050, 8ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Camilo Léllis, j. 26/04/2012, v.u.).

Aliás, embora tenha se declarado usuário de cocaína, em seu poder, foi também encontrada uma porção de maconha. E o réu não demonstrou ter renda suficiente para sustentar vício tão caro.

Impõe-se, portanto, a condenação do réu como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, cabendo anotar que, para sua configuração, não se exige qualquer ato de venda, bastando, como no caso em tela, que o agente traga consigo a substância entorpecente.

Consigno, outrossim, que o fato de o acusado ser usuário de entorpecentes, por si só, não infirma a acusação.

Com efeito, é comum que as figuras do usuário e do traficante se encontrem na mesma pessoa, eis que, muitas vezes, o usuário se vale do comércio ilícito de drogas para angariar recursos como meio de sustentar o uso, não ficando, com isso, isento de responsabilidade pela prática do crime de tráfico.

Nesse sentido: "A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura de traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade" (TJSP - RJTJSP, 101/498).

3. Passo, pois, à fixação da pena, observando o critério trifásico estatuído no art. 68 do Código Penal.

Atendendo-se às circunstâncias do art. 59 do Código Penal, observo que o réu é primário e não ostenta maus antecedentes. Assim, irrelevantes as demais circunstâncias, fixo a pena-base em cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa, em seu valor mínimo legal.

Não há circunstâncias agravantes e, porque fixada a pena no mínimo legal, nenhuma

atenuante pode reduzi-la.

Não há causas de aumento. De outro lado, não há notícia de que o réu integre organização criminosa ou se dedique a atividades ilícitas, razão pela qual reduzo a pena fixada de dois terços, nos termos do art. 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06, totalizando um ano e oito meses de reclusão e cento e sessenta e seis dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Quanto à substituição da pena corporal por restritiva de direito, muito embora, em tese, possível, comungo do entendimento de que a benesse é incompatível ao condenado por crime de tráfico, não em função de impeditivo legal, mas pela periculosidade social presumida, incompatibilizando o autor de delito dessa natureza com atividades comunitárias ou assistenciais, na medida em que o recoloca em contato direto com grupo suscetível ao seu assédio (cf. Apelação nº 0004555-80.2014.8.26.0451, Rel. Des. Augusto de Siqueira, j. 26.01.17).

Observe que o art. 44 do Código Penal, em seu inciso III, expõe elementos a serem considerados quando da substituição da pena corporal por restritiva de direito, consignando, ao final, a necessidade de que a substituição seja "suficiente".

Na hipótese, a substituição é medida insuficiente para a prevenção do abjeto comércio que se difunde e fomenta a delinquência no país, sendo, portanto, de acordo com a regra prevista no inciso III do referido diploma penal, imperiosa a manutenção da pena privativa de liberdade.

No que tange à fixação do regime inicial de cumprimento de pena, consigno que, com a edição do Novo Código de Processo Civil, aplicável ao processo penal em razão do disposto pelo art. 3º do Código de Processo Penal, estabeleceu-se a necessidade de os juízes observarem o precedente ao julgar determinada matéria.

Com efeito, o art. 926 do Código de Processo Civil dispõe: "Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente."

Já o art. 927 do mesmo código estatui: "Os juízes e os tribunais observarão: I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; II - os enunciados de súmula vinculante; III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional; V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados."

Prosseguindo, o art. 928 estabelece: "Para os fins deste Código, considera-se julgamento de casos repetitivos a decisão proferida em: I - incidente de resolução de demandas repetitivas; II - recursos especial e extraordinário repetitivos".

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus n.118.533/MS, firmou entendimento no sentido de que o denominado tráfico privilegiado de drogas não tem natureza hedionda.

Nesse contexto, anotou a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, no julgamento do Recurso Especial paradigma 1.329.088/RS, referente ao Tema 600 do Superior Tribunal de Justiça: "É sabido que os julgamentos proferidos pelo Excelso Pretório em Habeas Corpus, ainda que por seu Órgão Pleno, não tem efeito vinculante nem eficácia erga omnes. No entanto, a fim de observar os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, bem como de evitar a proliferação de decisões contraditórias nas instâncias ordinárias e também no âmbito deste Tribunal Superior de Justiça, é necessária a revisão do tema analisado por este Sodalícia, sob o rito dos recursos repetitivos".

E, de forma unânime, decidiu a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, Corte responsável pela interpretação da lei federal e sua correta aplicação, acompanhando o entendimento consolidado pela Corte Suprema, que o tráfico de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06) não é crime equiparado a hediondo, cancelando a súmula 512, editada em 2014 após o julgamento do REsp 1.329.088 sob o rito dos repetitivos.

Enfim, ressaltado meu posicionamento pessoal, estando pacificada nas Cortes Superiores a não hediondez do tráfico privilegiado, sendo o réu primário e imposta pena inferior a quatro anos, fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena.

Por fim, demonstrada a origem ilícita do dinheiro apreendido, declaro o seu perdimento.

4. Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para condenar o réu DIEGO FELIPE DOS SANTOS, qualificado nos autos, como incurso no art. 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06, à pena de um ano e oito meses de reclusão e cento e sessenta e seis dias-multa, no valor unitário mínimo legal, fixado regime inicial aberto.

Declaro o perdimento do dinheiro apreendido.

Oportunamente, expeça-se mandado de prisão a ser cumprida no regime aberto e, após o trânsito em julgado, procedam-se às anotações e comunicações necessárias.

Custas na forma da Lei nº 11.608/03.

Publicada em audiência, registre-se, intime-se, comunique-se, expedindo-se o mais necessário".

Pelo(a) Representante do MP foi dito que NÃO DESEJA RECORRER da sentença.

Pelo RÉU e DEFENSOR foi dito que NÃO DESEJAM RECORRER da sentença ora proferida.

Pela MMª. Juíza de Direito, a seguir, foi dito:

"1) Tendo em vista a EXPRESSA RENÚNCIA das partes ao recurso, dou a SENTENÇA por TRANSITADA EM JULGADO nesta data.

.

2) Tendo em vista a fixação de regime aberto para cumprimento da pena, expeça-se mandado de prisão de regime aberto. Cumprido o mandado, comunique-se o IIRGD e SARC e, após, expeça-se guia de recolhimento definitiva.

.

3) Cumpra-se a Res. 09/85 do TJSP, oficiando-se ao IIRGD e TRE.

4) Sai o réu intimado na audiência realizada nesta data, 22/02/2022, para que efetue o pagamento da multa no prazo de 10 (dez) dias, no valor de R\$6.445,68, equivalente a 201,62 UFESPs nos termos do Art. 50 do Código Penal e Art.479, caput, NSCGJ, sob pena de execução do débito a ser ajuizada pelo Ministério Público.

5) O réu foi assistido por Defensor Público, logo, está isento das custas processuais.

6) Oportunamente, archive-se.

Saem os presentes intimados".

CERTIFICO e dou fé que em sendo a audiência realizada virtualmente e havendo sido o presente termo de audiência lido, achado conforme pelas partes e assinado eletronicamente pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Piracicaba/SP, dispensam-se as assinaturas das eventuais testemunhas e vítimas, visto que os depoimentos são gravados em mídia. NADA MAIS. Eu, Diego Ricardo Lopes Cardoso Da Cruz, digitei.

Gisela Ruffo

JUÍZA DE DIREITO

[Assinado eletronicamente]